

1008348-97.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Fábio Rogério Bojo Pellegrino

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... autor, por não ter comunicado à ré o furto do aparelho e, por isso, a ré não tem qualquer responsabilidade; (4)aponta ter ocorrido fortuito externo, por ato de terceiros, sendo inaplicável a STJ 479; (5)impugna o pleito de desconstituição/declaração de inexigibilidade; (6)impugna os danos morais e o dever de indenizá-los.

Processamento: Houve réplica, seguindo-se novas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-901

1008348-97.2022.8.26.0008 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008348-97.2022.8.26.0008 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Matheus Trindade dos Santos

Requerido:

Nu Pagamentos S.a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a) Fábio Rogério Bojo Pellegrino

Ação: "DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR" entre as partes acima referidas, em que a parte autora ALEGA, em síntese, que teve seu aparelho celular furtado em 03/10/21 e que os meliantes, de posse do aparelho celular subtraído, fizeram empréstimo fraudulento junto ao réu no importe de R\$7.900,00, além de terem clonado seu cartão de crédito físico, efetuando compras de R\$7.000,00. Sustenta indevida negativação pela ré, com abalo creditício, vez que os débitos foram contratados fraudulentamente, ensejando, por isso, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Afirma ter sofrido busca e apreensão policial em sua casa, por responsabilidade da ré. Invoca o Código do Consumidor, a responsabilidade objetiva da ré, pela deficiência na segurança do serviço prestado pela ré e a inversão do ônus da prova nele previstas. PEDE: (1)LIMINAR para suspender os descontos dos valores do empréstimo contratado, bem como a suspensão da negativação; (2)declaração de inexistência do contrato de empréstimo de R\$7.900,00; (3)declaração de inexigibilidade do débito do cartão de crédito, de R\$7.000,00; (4)condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R\$20.000,00.

Liminar: concedida (fl. 78/79).

Contestação (fl.120/171), pela improcedência da pretensão inicial, em síntese:

(1)nega defeito na prestação de serviços; (2)as operações questionadas são válidas, vez que partiram de aparelho celular previamente autorizado pelo autor, com uso de senha; (3)culpa exclusiva do autor, por não ter comunicado à ré o furto do aparelho e, por isso, a ré não tem qualquer responsabilidade; (4)aponta ter ocorrido

fortuito externo, por ato de terceiros, sendo inaplicável a STJ 479; (5)impugna o pleito de desconstituição/ declaração de inexigibilidade; (6)impugna os danos morais e o dever de indenizá-los.

Processamento: Houve réplica, seguindo-se novas manifestações das partes sobre os documentos juntados pela parte adversa.

Relatei.

D E C I D O.

Matéria de direito, julgamento no estado.

Impugnada a contratação e a utilização do respectivo crédito pela parte consumidora, caberia à parte ré a efetiva demonstração de que foi ela, efetivamente, quem contratou com a ré e quem efetivamente se utilizou do crédito, não bastando a alegação de que foram efetuados em nome e por conta da autora. Neste ponto não cabe à parte autora a prova do negativo, isto é de que não procedeu à contratação impugnada, mas sim cabe à parte ré a prova do positivo, sob pena de reintroduzir-se no direito brasileiro a chamada "probatio diabolica", comum na Idade Média da época da Santa Inquisição e do Santo Ofício, o que não se pode admitir.

É que as fraudes são comuns, e mesmo sem saber o consumidor vem sendo constantemente lesado com contratações espúrias, em razão da evolução tecnológica das fraudes hoje em dia praticadas.

Assim, cabia à parte ré, nos termos dos art. 434 e 335, do CPC, demonstrar e juntar, na própria defesa ofertada, que foi a própria parte consumidora quem contratou e assumiu os débitos que ensejaram a negativação.

Porém, tal não foi feito: da documentação anexada à CONTESTAÇÃO não consta qualquer documento com assinatura da autora-consumidora, não servindo as "telas" anexadas para comprovar válida manifestação de vontade para formação do negócio jurídico em que se baseiam os débitos que deram origem às negativações em desfavor da parte consumidora.

Por isso, ausente prova escrita - que deveria acompanhar a defesa, já que prévia à discussão dos autos, não ocorridas as hipóteses do CPC 435 - impõe-se o acolhimento da pretensão da parte autora, pelo reconhecimento de fraude, com a desconstituição da contratação, dos débitos e das restrições decorrentes.

Releva notar que, no caso, há sérios indícios de fraude na contratação, já que os débitos no MEPHISTO BAR, de R\$2.900,00, de R\$1.900,00 e R\$2.200,00, num único dia (10/10/21) - fl. 127 - além de não ser verossímil que uma pessoa gaste tudo isso em um único dia num bar-restaurant/balada, gastos estes que fogem também ao perfil de gastos da parte consumidora - fl. 23/29.

Em consequência, responde a instituição financeira pela indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Ora, se é o banco/ instituição financeira quem faz a inscrição negativa em desfavor do consumidor, cabe a ele, banco/instituição financeira, demonstrar a legitimidade do débito, ou de que partiram efetivamente da parte consumidora, quando impugnados os lançamentos ou a contratação pelo consumidor.

A condenação independe de culpa, não se aplicando, no caso, o art. 186, do Código Civil. A responsabilidade do banco/instituição financeira ora acionada é objetiva, por defeito na prestação de serviço, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que não apresenta a segurança que legitimamente dele se espera, permitindo contratação fraudulenta e lançamentos indevidos, decorrentes de fraudes. Não há negativa de vigência ao art. 373, do Código de Processo Civil, pois a instituição financeira é quem deveria fazer prova de que foi a parte autora realmente a responsável pela contratação e lançamentos impugnados.

O art. 14, § 1º, do CDC esclarece que "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido".

O fornecedor só não será responsabilizado, nos termos do art. 14, § 3º, quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, nem o caso fortuito e a força maior foram incluídos no rol das excludentes da responsabilidade civil do fornecedor de serviços (cf. Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Saraiva, 6ª edição, 1995 - item 50, pág. 259).

Neste contexto, ainda que possa decorrer a contratação fraudulenta por terceiros, a responsabilidade do réu é objetiva na forma do art. 14, "caput" do Código de Defesa do Consumidor, vez que o réu contribuiu para as fraudes, propiciando as contratações sem quaisquer formalidades mínimas, que permitam a verificação da identidade do contratante e facilitando, assim, as ações criminosas dos larápios. O serviço prestado pelo réu, como se apontou, é defeituoso, na forma do que dispõe o art. 14, §1º, do Código do Consumidor, sendo descabido o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro pelos motivos apontados.

Quanto à culpa exclusiva da consumidora, tal alegação não encontra qualquer suporte, já que decorrente de mera ilação advocatícia, sem contextualização no tempo e no espaço, não demonstrando concretamente em que sentido tenha se dado a suposta "negligência" da consumidora na guarda do aparelho celular, ao passo que cabia à parte ré a demonstração de que foi a consumidora quem contratou, o que não ocorreu.

A comunicação do furto do aparelho, ainda que tardia, não exime a fornecedora da responsabilidade quanto à falha na segurança dos serviços.

A alegação de falta de dano à parte autora, decorrente de sua inclusão nos cadastros de maus pagadores, não pode ser acolhida: trata-se de cadastro público, divulgado a todos, para facilitar a aquisição regular de bens e serviços, especialmente os financeiros, sendo que a simples inscrição nestes cadastros creditícios, tais como SERASA, SCPC, EQUIFAX etc, é suficiente para provocar abalo ao crédito.

E em se tratando de indevida inscrição, como é o caso dos autos, decorrente de contratação fraudulenta à revelia do consumidor e em razão do defeito do serviço, como já apontado acima, deve a parte ré arcar com a respectiva indenização por danos morais, em favor da parte consumidora.

Neste contexto, e comprovadas o apontamento do nome da parte autora às fls. 49, nos cadastros de proteção ao crédito, que só foi obstado por força da liminar deferida por este Juízo às fls. 78/79, entendo justa a indenização por indevido abalo creditício em favor da parte autora, no montante de R\$10.000,00, atualizando-se conforme Súmula 362, do STJ.

Quanto ao fato da busca policial na casa da parte autora, não há qualquer indício de que tenha sido decorrência de falsa comunicação de crime pela parte ré, o que, por isso, não enseja indenização adicional a tal título.

Por fim, observo que o autor não pede a condenação à devolução de valores indevidamente descontados a título dos débitos e do empréstimos, sendo que ao Juízo é vedado concedê-lo (CPC Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado).

É o que basta para o deslinde.

1. Dispositivo: Isto posto, nos termos do CPC 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de:

I - DESCONSTITUIR o EMPRÉSTIMO de R\$7.800,00 (sete mil e oitocentos) - conforme fl. 126 - contrato 0129400187248170 (fl. 49) e os respectivos débitos dele decorrentes, reconhecendo-os como INEXIGÍVEIS, pelos motivos acima apontados.

II - DESCONSTITUIR os lançamentos a débito ocorridos na conta corrente do autor, realizadas no MEPHISTO BAR, de R\$2.900,00, de R\$1.900,00 e R\$2.200,00, todos do dia 10/10/21 (fl. 167) reconhecendo-os como INEXIGÍVEIS, pelos motivos acima apontados.

III - TORNAR DEFINITIVA a LIMINAR de fls. 78/79 para ORDENAR a EXCLUSÃO DEFINITIVA das restrições pendentes sobre o nome da parte autora em relação ao contrato nº 0129400187248170 (fl. 49) e os respectivos débitos dele decorrentes

IV - CONDENAR o réu a PAGAR à autora indenização por danos morais no importe de R\$10.000,00 (dez mil reais) corrigida monetariamente pela Tabela do Tribunal de

Justiça a partir da data desta sentença, conforme Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do Código Civil/2002 c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional), a contar do trânsito em julgado desta sentença ou da data da publicação do acórdão, do qual não caiba mais recurso com efeito suspensivo, quando então se torna exequível e exigível coativamente a indenização fixada.

2. CONDENO a parte ré, ainda, a pagar à parte autora o reembolso de custas, despesas processuais, devidamente corrigidas, bem como honorários advocatícios no importe de R\$ 5.058,54 (CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme CPC 85, §8º e §8º-A, introduzido pela Lei 14.365/22, corrigindo-se monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde a data desta sentença, com juros de mora na taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

(Art. 85. § 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)).

3. Eventual protocolo de embargos de declaração dever ser inserido com a denominação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO código 38027 e apelação com a denominação RAZÕES DE APELAÇÃO código 38023.

Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de EMBARGOS de DECLARAÇÃO que visem a discutir o mérito da decisão serão considerados protelatórios, passível de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC), sendo que tais decisões devem ser atacadas pelo recurso cabível.

Como preparo de apelação ou de eventual recurso adesivo, a parte recorrente deverá recolher o importe de 4% sobre o valor da causa (Art. 698, II, das NSCGJ e Art. 4º, II, da Lei nº 11.608/03, alterado pela Lei nº 11.855/15). Na hipótese de se processar nos mesmos autos mais de um recurso, cada recorrente deverá recolher por inteiro seu respectivo preparo (Art. 698, §4º das NSCGJ).

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa. Conforme disposto no art.1.275,§3º,das NSCGJ, em caso de existência de mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância,a parte apelante deverá providenciar o recolhimento referente à(s) prova(s)

material(ais)anexada(s) ao processo,inclusive mídia(s) de audiência, utilizando a guia do FEDTJ, código 110-4, observando, para tanto, o valor indicado no artigo 3º do Provimento CSM nº 2.516/2019 (DJE, 02/08/2019, Caderno Administrativo, Pág. 02). Com o trânsito em julgado, tendo em conta o Provimento CG n. 16/2016 e Comunicado n. 438/2016, a parte exequente deverá dar início à execução da sentença (Cód 156 - que fará com que o sistema informatizado cadastre automaticamente o incidente de Cumprimento de Sentença, para onde as partes deverão, doravante, direcionar todas as peças subsequentes), no prazo de 30 dias, facultado ao exequente incluir em sua planilha de cálculo o valor das custas finais(1% sobre o valor da satisfação da execução, respeitado o mínimo legal de 5 UFESPs vigentes),previstas no art. 4º, III, da Lei nº 11.608/03.

Decorrido o prazo sem providências, arquivem-se os autos.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA